

大阪地方裁判所第2民事部御中

鑑 定 意 見 書

大阪府外形標準課税条例の適法性について

立命館大学法学部教授
博士（法学・一橋大学） 三木 義一

平成14年9月27日

目次

- I はじめに
- II 鑑定意見書の結論
- III 本件条例と地方税法
 - III-（１）地方税法７２条の１９と本件条例
 - III-（２）物税としての事業税
 - III-（３）事業税の課税標準
 - III-（４）事業税の法的性格
 - III-（５）物税としての「所得」
 - III-（６）事業の情況
 - III-（７）業務粗利益
 - III-（８）同一業種内の区別
 - III-（９）均衡要件
 - III-（１０）不均一課税
 - III-（１１）法定外新税
 - III-（１２）本件条例と憲法
- IV おわりに

I はじめに

筆者は長年大学において税法の研究・教育に従事してきた。このたび、大阪府より専門の立場から「大阪府における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例（以下、「本件条例」と略す）の適法性についての意見を求められた。専門家としての公正な立場から原告が本件訴状（平成１４年４月４日付）で主張している本件条例の地方税法違反の論点に絞って意見を申し述べるものである。

II 鑑定意見書の結論

１ 原告は本件条例の地方税法第７２条１９違反を主張するが、本件条例は同法第７２条１９の要件を満たしている適法なものである。原告の解釈方法は特定の条文の文言のみから自己に都合のいい結論を引き出す強引な解釈方法であり、少なくとも地方税法における事業税の諸規定を体系的に解釈したものとは言い難い。

２ 原告は本件条例が均衡要件（地方税法第７２条の２２第９項）にも違反していると主張するが、本件条例は同法第７２条の２２第９項の要請を十分に満たしている。逆に、原告の解釈は、地方税法第７２条の１９が外形標準課税の特例を設けた意義を全く失わせてしまう解釈である。

３ 原告は本件条例が不均一課税（地方税法第６条第２項）にも反していると主張するが、

本件条例は地方税法第72条の19の要件を満たしている以上、一般規定である不均一課税の問題には抵触しない。原告の主張は地方税法における一般規定と、個別税目における特例規定の要件の関係を混同した解釈であり、地方税法を体系的に解釈したものとは言い難い。

4 原告は本件条例を憲法14条の平等原則違反を主張するが、本件条例は平等原則には反しない。それどころか、現実の事業税負担が不平等になっている状況のなかで、積極的に平等・公平な税負担を実現しようとしたものである。

以下において、より詳細に上記結論の理由を述べることにしたい。

Ⅲ 本件条例と地方税法

前述のように、本意見書では、本件原告が提出している平成14年4月4日付訴状で指摘されている論点を中心に述べることにしたい。また、必要に応じて本件条例とほぼ同内容の「東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例」に対して東京地裁民事3部が示した平成14年3月26日判決（以下、「東京地裁判決」と略す）の内容についても言及することにしたい。

なお、新たに立法された税法及び税条例の適法性の判断にあたっては、特定の条文の文言のみを取り出し他の条文との相互関係を無視する恣意的な解釈は避けねばならず、関連条文との体系的な理解がとりわけ要求されることを強調しておきたいし、本意見書もできるだけそのような姿勢を貫くよう努力したつもりである。

（１）原告は訴状においてまず、次のように本件条例を批判している。「地方税法72条の19は、『事業の状況に応じ』外形標準課税の採用が必要である場合に限って、極く例外的に外形標準課税を採用することを認めている。したがって、本件条例が同条項に照らして適法であるか否かは、本件条例が『事業の状況に応じ』必要であると評価できるかどうかによることになる。その点、憲法の要請から離れて地方税法の規定について地方公共団体による任意の解釈を許す場合には、地方公共団体の条例制定権に法律の範囲内という限界を定める憲法94条に反することになるだけでなく、ひいては『人の支配』を許す結果になり、憲法の立脚する『法の支配』の原理を実現し得なくなる。そのため、地方税法72条の19の文言の解釈は、憲法及び地方税法の目的・趣旨から厳格に制限されなければならない。」

しかし、憲法は地方自治を保障し（憲法92条）、事業税の課税も含まれる自治事務については「国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるように特に配慮しなければならない」（地方自治法第2条13項）と規定し、地方税法も72条の19において、条例制定に際しての国の関与（例えば、法定外税の場合の地方税法259条等参照）を排除し、具体的な制定条件を設けることもできたのにあえて「事業の状況」という抽象的な条件にとどめ、税率等についても具体的な制限規定を設けずに「著しく均衡を失することがないようにしなければならない」とするにとどめているのである。憲法が要請する地方自治の本旨と、地方税法が緩やかな条件に止めていることを体系的かつ適切に解釈すれば、本件規定は自治体の立法裁量を尊重した上での枠であって、原告の主張

するような結論には到底達しえない。

(2) 次に、原告は「まず、地方税法は、法人事業税について、その物税としての基本的性格に基づいて、明示的に例外とされる例外4業種を除き、業種等の人的事情による区別を許さず、すべての業種について一律に「所得」を課税標準とし(同法72条の12)、すべての業種について可及的に均一の取扱いをすることを旨としている。」と主張する。

この主張で奇妙なのは、「物税」という性格論から「一律に…可及的に均一の取り扱いをすることを旨としている」という点である。物税は一般に課税対象物の価値自体を課税標準とするもので、その課税対象を有している納税者の人的事情を考慮しない税制を意味し、例えば、固定資産税のように固定資産の価値に着目している場合には、当該固定資産を誰がどのような事情で所有しているかに関わりなく、固定資産の価値が同一であれば同一の負担額になる税制である。物税の核心は課税標準の中に人的事情(例えば、各種人的控除)を持ち込まない点にあり、それ以上のものではない。ましてや、物税であることから「すべての業者に対する均一の取り扱い」が導かれるものでもない。現行固定資産税をみても、家電や送電施設に対する課税標準の特例(地方税法第349条の3)や住宅用地に対する課税標準の特例(地方税法第349条の3の2)等の規定があり、決して物税＝均一取り扱いが要求されるわけではない。あるいは、原告は「明示的」規定がある場合は許される、というのかもしれないが、そうであれば、地方税法は72条の19で明示的に外形課税しうる余地を認めているので、本件条例が地方税法72条の19の要件を満たしていれば何ら問題はないことになる。

さらに奇妙なことは、「地方税法72条の19を適用する場合も、例外4業種を除き、すべての業種について可及的に均一の取扱いをする趣旨」なので、本件条例のような特定業種に適用したのは、「『事業の状況に応じ』という要件を満たさない」という指摘である。これによると、本条に基づく条例は例外4業種以外の全業種を対象にしなければならないことになり、そうすると、現行地方税上の例外として規定されているはずの地方税法72条の19に基づく本件条例により、当該自治体の事業税はすべて外形標準課税ということになり、地方税法の規定を全く形骸化してしまうことになる。

なお、原告が本件訴状で、事業税を「物税」とであると自認していることにも注目しておきたい。物税は前述のような性格から応能負担にはあまり適合的な税制ではないと一般に解されているからであり、少なくとも事業税は「所得」を課税標準としてはいるが、人税としての応能負担に配慮した所得税の「所得」ではなく、物税としての「所得」を原則的課税標準しているにすぎないことを自認したものと見て重要である。

(3) 次に原告は「特定の業種にのみ本条を適用することが直ちに違法とならないと仮定するとしても、事業税ではあくまでも所得を課税標準とするのが原則であり、その例外については厳格に解すべきである」という。この主張は地方税法第72条12が『法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業にあっては各事業年度の収入金額、・・・(中略)・・・その他の事業にあっては各事業年度の所得及び清算所得による。』と規定し、同法第72条の19が事業の状況に応じてその他の基準を用いることができると規定していることを根拠にしているものと思われる。原

告及び原告側を支持する意見書の多くはこの72条の12の文言をことさらに強調して、法人事業税が「所得課税」であり、その例外は厳格に解釈しなければならないとしている。しかし、地方税法はまず72条1項で、法人については「法人の行う事業に対し・・・所得金額、清算所得、収入金額・・・を課税標準として・・・その法人に課する」という原則規定を設けていることも疑うことのできない事実であり、所得と収入金額を同列に位置づけて事業税が「所得」に対して課税するものではなく、「事業」に課税するものであることを明示した上で、同法第72条の12で4業種以外の業種については「所得及び清算所得」を課税標準にすること、同時に、同法第72条の19で「事業の情况」に応じて所得以外の基準で課税できる余地を認めているのである。こうした地方税法の体系を前提として解釈するならば、現行法上は確かに法人に対して所得以外の基準で課税するのは例外的といえるが、原告主張のように厳格に解されるべきものではなく、むしろ所得という課税標準では「事業」自体に負担を求める事業税の性格にふさわしくない場合は、他の課税標準を採用する余地を広く認めていると解すべきもののなのである。原告の主張は72条の19の文言だけに着目した恣意的な解釈といわざるを得ない。

(4) なお、原告は「事業税はあくまでも所得を課税標準とするのが原則」であることを強調し、あたかも事業税が所得課税であるかのような主張し、このことが東京地裁判決の誤った事業税解釈ともつながっているので、事業税の法的性格についても述べておきたい。

東京地裁判決は、次のように判示している。

「現行の法人事業税についての定めをみると、課税標準については、地方税法72条の19（これは72条の12のミスであろう・・・筆者注）により『法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業にあっては各事業年度の収入金額、・・・（中略）・・・その他の事業にあっては各事業年度の所得及び清算所得による。』と定められ、課税標準は、原則として『各事業年度の所得及び清算所得』とし、電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業の例外4業種については例外的に『収入金額』としている。したがって、少なくとも現行地方税法の解釈においては、地方税法72条の12が大半の業種について所得を課税標準としていることから、事業税が『所得課税』という意味での応能課税の立場を原則としていることは否定できない。」

地方税法72条の12の条文を重視して、そこから事業税の性格を引き出し、事業税は応能課税の立場に立った所得課税だとしているわけである。このうち、応能課税かどうかの問題は原告が訴状で本件事業税が物税であることを自認しているので、これ以上立ち入らないが、東京地裁判決はいくつかの基本的な誤りを犯している。

まず第1に、租税の法的性格を一つの条文だけから引き出し、本件の場合は課税標準規定から強引に「事業税＝所得課税」論を引き出している。原告側の意見書等にもしばしば同様の指摘が見られるが、解釈論としてきわめて疑問である。もし、このような解釈が可能ならば、例えば、消費税法第28条は「課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額とする」と規定しているので、消費税の基本的性格は売上税である、ということになる。しかし、学説、実務も消費税が付加価値税であることを前提としており、例えば東京地裁平成9年8月8日判決（行集48巻7・8号539頁、等）も「消費税は、・・・各取引段階において移転、付与される附加価値に着目して課される附加

価値税の性質を有する多段階一般消費税であって、各取引において附加価値の移転等がある場合は課税の問題が生じるが、附加価値の移転等が生じない場合は理論上は課税の問題は生じないものである」と述べているのは周知の通りである。学説・実務が課税標準自体は売上税の形式を採用している消費税に対して付加価値税という性格付けをしているのは、同法が課税標準規定の後の第30条で「仕入税額控除」を規定しており、条文を体系的に理解するならば同税の法的性格は付加価値税であるといわざるを得ないからである。ある税の法的性格から個別規定を解釈する場合には、まずその前提として当該税の法的性格を体系的に理解することが必要不可欠である。

第2に、このような視点から地方税法を検討すれば、前述の地方税法第72条の規定に加えて、地方税法は事業税が所得課税ではないことを様々な条文で明らかにしていることに気づいたはずである。例えば、72条の14では課税標準は法人税法の所得そのものではなく、各種の加算減算をすることを要求している。これは、事業税の課税標準を所得に依拠しつつも事業規模にふさわしいものに修正するための規定である。もっとも、わが国の地方税法72条の14は技術的な修正にとどまっているので、この点が見えにくくなっている。しかし、わが国の地方税法は72条の15で、海外の所得を除外することを独立の条文で規定している。この条文は、事業税が所得課税ではなく、事業そのものを課税客体とするものであり、「事業とは国内における事業と解される」（例えば、自治省府県税課編『事業税逐条解説』平成7年、地方財務協会213頁参照）ことを明らかにするための規定である。原告及び東京地裁判決のように事業税を所得課税だとするのであれば、海外の所得を課税標準から除くことを合理的に説明することは不可能である。

また、事業税が所得課税だとすると、その場合に現行法が事業税を所得計算に際して損金としていることを（法人税法38条3項参照）どう説明するのだろうか。所得課税であれば、事業税は「所得」に税率をかけて求められるべきものだから所得計算過程で控除してはならないはずである。この点を、東京地裁判決は「これらは、あくまで所得税法及び法人税法がそれぞれ所得税及び法人税の課税標準を算出するに当たって事業税をどのように扱うかという技術的な規定にすぎない」と逃げている。事業税を所得課税であると理解すると論理的に説明できない現行法の制度を「技術的なもの」に退けているのである。しかし、「所得」課税である租税を「所得」から控除したら、課税標準としての所得の算定は不可能になりかねないのであって、単なる技術的なものではないのである。

第3に、仮に原告及び東京地裁判決のように事業税を所得課税であるとすると、現行の道府県民税と抵触し、同一の課税団体が同一の課税標準に二重の課税をすることになってしまう。二重課税を禁止する規定はない、という反論は無意味である。なぜならば、これはそもそも立法上の当然の原理であり、既存の税制と課税理念、課税対象、課税標準等が同一なら、何も新税を導入する必要はなく、税率を調整すべき問題であることは何人も否定しえないであろう。現行地方税法の立法者が、住民税とは別個に事業税という税目を都道府県に導入したのは、住民税とは別個の課税理念、課税対象を想定していたからであり、一見課税標準が住民税と似ているからといって、住民税同様所得を課税対象とする租税だと解したら、何のために事業税が導入されているのか全く説明できないであろう。立法者は二重課税にならないように新税を導入しているという当然の前提を理解した上で、条文

全体をすこしでも調べれば、事業税が住民税と同一の所得課税などではないことは容易に理解できたはずであるし、事業税を体系的に解釈できたはずである。

このように、現行地方税法は法人事業税については確かに「所得」を原則的課税標準に採用しているが、事業に課税するための指標として所得を課税標準に適用しているにすぎず、所得税とは異質な税制であることをまず理解すべきであり、原告の主張はこの前提を誤っていることに留意すべきである。

(5) 原告がすでに事業税が物税であることを自認しているので、簡単な言及にとどめておくが、事業税は「所得」を原則的な課税標準としてはいるが、この「所得」は人税としての所得税の「所得」ではなく、あくまでも物税としての「所得」であることにも留意しなければならない。しばしば、所得課税は応能課税に適合的といわれるがそれは「所得」課税だからではない。所得課税であっても物税的に構成して単純に「所得」そのものに課税するシステムが採用された場合、応能課税原則に反することもありうるのである。たとえば、高齢の両親や幼い子供を扶養しているAさんと独身のBさんが同額の所得を得れば同額の税負担になるようにすることも「所得」税では可能である。しかし、それでは負担の公平を歪めるので、扶養控除等の各種の人的控除を通じて納税者自身の人的負担能力を配慮しているのであり、それが所得課税の応能化に貢献しているのである。つまり、単に所得課税だから応能であるわけではなく、所得課税は人的控除を通じて人税的に構成しやすいから応能原則に適合しやすい税制なのである。ところが、事業税が課税標準にしている「所得」はこのような所得ではないのである。なぜなら、事業税が課税標準にしているのは、個人事業については「事業の所得」であり、事業主控除という政策的控除を除いては所得税のような人的控除はないからである。つまり、事業税は事業規模を間接的に推計する指標として人的控除のない「所得」を課税標準にしているのであって、この意味での事業所得があれば、どのような人的事情で当該事業を営んでいるかには関係なく課税する物税的な制度であり、所得税のような人税とは根本的に異なっているのである。その意味で、納税者の個々の人的事情を加味した担税力に着目したものではなく、事業そのものの担税力としての事業所得に着目した税なのである。東京地裁判決は、こうした点の理解が欠けているといわざるを得ない内容のものである。

(6) 原告は上記のような誤った前提で、次に「地方税法の趣旨に鑑みるならば、地方税法72条の19が定める『事業の状況に応じ』の要件は、例外4業種の場合と同程度の必要性和合理性が存在する場合、すなわち、事業構造の客観的特性ないし特別の法制度により、所得を課税標準としたのでは事業税負担が恒常的に過少となる場合にのみ充足される。しかし、銀行業等の場合の近年の事業税負担の減少は、その時々¹の景気変動による事情によるものにすぎず、『事業の状況に応じ』の要件を満たしていない」という。

しかし、これは、上記のように現行事業税が所得課税であるという誤った前提に立った議論である。事業税が、原告主張のように、所得課税だとすれば、所得以外の課税標準の採用を認める「事業の状況」は厳格なものと解する余地がある。しかし地方税法は法人事

業については所得以外の課税標準を原則として認め、さらに様々な規定で事業に課税するものであることを明記した上で、本件の例外規定も設けているのである。こうした点を総合すると、外形標準を許す「事業の状況」という要件は、事業税の本質との関係からみても、「所得で課税するとかえって不公平になる事情を広く含む」ものと解される。

この点、原告は「例外4業種の場合と同程度の必要性和合理性が存在する場合、すなわち、事業構造の客観的特性ないし特別の法制度により、所得を課税標準としたのでは事業税負担が恒常的に過少となる場合のみ」に限定すべきであるとしているが、例外4業種とほぼ同様の基準が必要であるというなら、そのような事情はなにも自治体が条例制定をするまでもなく地方税法の改正で対処しうるものであろう。また、その場合、自治体がこの条文から独自に条例を制定出来るのは、当該自治体内に例外4業種と同様な客観的事情がある場合に限定されるが、そのような業種を特定自治体内に見いだすことは現実的にはあり得ず、結局、独自に課税しうる自治体はまず存在しないことになる。また、何よりも同条の規定からみて原告のような著しく限定した解釈は不合理だと思われる。なぜならば、地方税法第72条の19は「事業の状況に応じ、・・・所得及び清算所得によらないで、資本金額、売上金額、家屋の床面積若しくは価格、土地の地積若しくは価格、従業員数等を課税標準とし、又は所得及び清算所得とこれらの課税標準とをあわせ用いることができる」としか規定していないからである。原告のような前提で立法されているならば「例外4業種以外の業種の課税標準についても、例外4業種と同様の事業の状況が認められる場合には・・・所得以外の課税標準を用いることができる」というような規定になっていたはずである。原告の解釈方法は、事業税の性格については、現行地方税法の課税標準規定の文言重視の解釈をしておきながら、例外規定となるととたんに目的解釈に転換している恣意的な解釈といわざるを得ない。

(7) 次に原告は「『事業の状況に応じ』の要件が充足される場合でも、地方税法72条の19において採用され得る外形標準は、法人事業税の課税標準として適切かつ合理的なものでなければならない。しかし、本件条例が外形標準として採用する『業務粗利益等』は、適切かつ合理的な基準ではなく、地方税法72条の19が認める課税標準ではない」としている。しかし、この主張が何を根拠にしているのかは全く不明である。業務粗利益は企業の収益力を示し、銀行の事業活動規模を示す優れた基準であることは企業会計の専門家の意見でも明らかにされている（この論点については、東京都条例の控訴審で東京都側から提出されている、山口孝・明治大学名誉教授及び山口不二夫・青山学院大学教授の両鑑定意見書が重要である）。むしろ、問題なのは、業務粗利益が売上総利益とは異なる異質な概念であるかのように強弁し、東京地裁判決もそれに引きずられ「銀行の業務粗利益が一般事業会社の売上総利益に相当するものでない」、「それは、前者が貸倒損失を控除していない点にある」、「この額を控除しない業務粗利益は、売上総利益とは異なったものといわざるを得ない」、「このような重要な点を反映しない業務粗利益をもって課税標準としたことは、条例の立案に当たって、当然に考慮すべき点を考慮しなかったに等しい」、「その点につき誤った説明をした主税局長には、やはり重過失に近い過失があった」（同判決57～58頁）と判断していることの方がはるかに問題であろう。売上総利益は「売

上高」から「売上原価」を控除した、いわゆる「粗利」であり、損益計算書上、貸倒損失を控除する前に計上されているのであって(実務家からもこの点の誤りが指摘されている。例えば、粕谷晴江「銀行税訴訟の考察」税件103号64頁)、両者はいずれも貸倒損失は控除されていないので、「前者が貸倒損失を控除していない点」に差異を求めている東京地裁判決自体が誤っていたのである。業務粗利益が事業規模を適切に反映した優れた指標である点については、専門家の鑑定意見を参照いただきたい。

(8) 次に原告は「本条は『事業』の状況による区別を許容するのみであり、銀行業等という同一『事業』の中において、さらにその『資金量』によって区別することまでは許容していない」という。しかし、前述のように、地方税法は「事業の状況」に応じて適切な課税をすることを広く許容しているのであって、特定の事業を選択した場合に当該事業全体に例外規定を適用すべきことを強制してはいない。従って、特定事業のうち、どの範囲まで例外規定を適用するかも事業の状況を配慮して立法しうるのであり、基本的には立法裁量の問題である。本件条例の場合、資金量5兆円以上の大手銀行の事業税負担が銀行業全体の事業税負担の82%をも占め、その部分の税収の落ち込みが激しかったことが条例制定の背景にあり、中小金融機関への配慮という政策的要素も加味して資金量5兆円を基準にしたというのであれば(被告準備書面(2)26頁)、そこには一定の合理性がみられ、裁量を逸脱しているとは到底言い得ない。確かに、5兆円という基準で区分することには不公平感があり得るが、課税対象を限定する場合、一定の数値的基準で限定せざるを得ないのであり、それ故、例えば、消費税の免税点の場合も、課税売上3000万円が基準であるが、なぜ3000万円なのか、それが不公平につながらないかについて東京地裁平成2年3月26日判決(判例タイムス722号222頁、判例時報1344号115頁、税務訴訟資料176号194頁)は、「年間売り上げ金額が3000万円以下の事業者が右制度により利益を得ることになり、右限度額の当否が租税政策目的上妥当であるか否かの問題はあろうが、立法上右制度による程度の差別が現段階で不合理であるとまでいいきれない」と判示したのであるし、住宅所得控除の適用対象となる最低床面積が改正により50平方メートルに引き上げられ、引き渡しが遅れたため特例対象とならなかったことの平等原則違反が争われた事例でも、東京地裁平成10年2月26日判決(判例タイムス1000号275頁参照)は「住宅取得控除のような住宅取得者に対する税制上の優遇措置を設けるかどうか、設けるとする場合にその制度内容をどのようなものにするかについても、立法府は広範な裁量権を有しているというべきである」と判示し、改正により適用に差が生じることについては「やむを得ないことであり、これをもって不合理な差別ということはできない」としてきたのである。本件条例のように外形標準課税の適用要件を資金量5兆円以上の銀行業に限定した点についても、同様の判断基準が妥当しよう。

(9) 次に原告は地方税法72条の22第9項の均衡要件についても、次のような「奇妙な」限定解釈を展開している。

すなわち、「地方税法72条の22第9項は、外形標準課税を課する場合の税率は、所得を課税標準とする場合の負担と『著しく均衡を失することのないようにしなければならない』と規定する。この均衡要件については、実際に本件外形標準課税による負担が生じる事

業年度ないし直近の年度における、(イ)所得を課税標準として計算した場合の法人事業税の負担と(ロ)外形標準課税による場合の法人事業税負担とを比較して、『著しく均衡を失する』か否かを判断する必要がある。この点、本件条例の場合、原告らに対して本件条例が適用される結果、所得を課税標準とする従来の法人事業税負担と比較すると、本件条例による法人事業税の負担は、原告らに対して法外に重い過酷な税負担を課するものとなっている。よって、本件条例は、所得を課税標準とする事業税と比較すると、明らかに『著しく均衡を失する』事業税を課するものであり、地方税法72条の2第9項に違反する。」

しかし、仮に、この主張が、ある年度もしくはその直近の事業年度における現実の所得金額を課税標準とした場合の税負担と、外形標準を導入したことによる当該年度の税負担が「著しく均衡を失してはならない」、という意味なら、外形標準課税の存在理由はなくなってしまう。なぜなら、本件特例を適用して外形標準で課税するのは、当該事業年度の各事業の現実の所得では当該事業の担税力を適切に表せないと判断されたからこそであり、この場合の税収が現実の所得に課税した場合と差がでないようにしなければならないのであれば、外形標準課税を導入する意義が全く失われてしまうからである。本件で問題となっている銀行業のように不良債権処理により他業種に比しても極端に事業税負担が低くなったために、より適切な事業税負担を求めるために外形標準課税を導入せざるをえないのに、その場合の税収が極端に落ち込んでいる年度と均衡を失してはならないのだとしたら、何のために地方税法はこのような特例規定を設けたことになるのか、全く説明できなくなる。これは条文解釈以前の常識問題のようにも思われる。この規定は、特例規定導入を奇貨として、所得を課税標準にしていた場合に通常生じる負担よりも重い負担を求めることを諫めた規定であり、本件特例が所得を課税標準としていては事業規模を適切に反映した負担が求められなくなったことを調整するにすぎないものであることを明らかにしているのである。地方税法が本当に原告主張のような前提でこの規定を設けたというのであれば、一体いかなる場合に事業の状況に応じて外形標準課税を導入する必要があるのかを原告側は説明すべきである。筆者が唯一想定できるのは、導入年度は所得基準と同じでも将来的に外形課税にした方が税収の上がることが予測される場合であるが、しかし、将来的に外形課税の税収がのびる事業であれば、所得基準による税収ものびるのが通常であり、あえて外形課税にする必要もないはずである。

したがって、この「均衡」は当該事業の現実の所得ではなく、当該事業において過去通常に生じていた税負担との対比において検討されなければならない。原告を支持する意見の中には、この均衡を当該年度又は直近の単年度の所得を基準にした税負担を比較し、しかも、1.1という制限税率を例に出して、1.5倍を超えたら違法で、1.2倍を超えても違法の疑いがある、とするものもある（例えば、東京地裁に銀行側の意見書として提出された平成14年1月11日付の碓井教授の意見書）。しかし、この見解によれば、所得を基準にした場合の税負担が一定の理由により、従来の税負担の5%程度になったために、納税者間の不平等を是正し、せめて従来の税収の80%程度を確保しようとして本件特例を導入すると、それは1.6倍もの負担増で違法となり、可能なのは1.1倍の5.5%程度の税収確保だけということになる。このようなことしか本件特例ができないのであれば、わざわざ特例適用に踏み切る必要はない。いずれにせよ、このような解釈は本件特例の意義を失わせてしまう。この規定は、所得基準の場合に通常生じる税収が、事業の状況のた

めに生じなくなったことを是正するための措置であるから、比較されるのは所得課税の場合に当該特殊要因がなかった場合に通常生じる事業税負担である。その場合の対比すべき税負担は恣意的にならないように一定の長期間のデータに基づく必要があると思われる。この点からすると、本件条例は、過去15年間という長期の銀行業における税負担を勘案して、その税率や負担額を制定しており、特定期間の数値のみを基準にして恣意的に有利な数字を採用することを避ける配慮をした上で導入されているのであって、これを「著しく均衡を失する」と非難するのは全くの的はずれの解釈であるといわざるを得ない。

(10) さらに、原告は不均一課税問題にも言及し、本件条例が地方税法6条2項に違反しているとして、ここでも「奇妙な」議論を次のように展開している。

「本件条例は、資金量5兆円以上の金融機関のみに対し、課税標準を業務粗利益として事業税を課するものであるが、資金量が5兆円以上か、それ未満かによって課税標準を異ならせているという点で、本件条例は地方税法6条2項に定める『不均一の課税』に該当する。しかし、本件条例は、かかる規定に従った措置を採ることなく制定されており、また同規定の『公益上その他の事由』も存在しておらず、地方税法6条2項に違反し、違法である。」

しかし、地方税法第6条2項の規定は、いうまでもなく、地方税全税目について不均一な課税を認める要件を規定したものであり、全税目を対象とした一般規定である。この一般規定に基づく不均一課税は、あくまでも地方税法上の各税目に対する特例規定がない場合に適用されるものであり、同時に、地方税法は各税目のそれぞれの趣旨に相応しい多くの特例規定も設けているのである。しかも、このような特例規定は不均一な課税を結果としてもたすが、当該税目に関わる具体的必要性から設けられているので、当該特例の要件に該当すれば一般規定の要件を問題にすることなく違法の問題は生じないはずである。これを原告のように解すると、例えば固定資産税における新設大規模償却資産の課税標準の特例（地方税法349条の5）等も不均一課税をもたらし、しかも同規定には地方税法第6条2項を排除する明文の規定がないので、第6条2項が適用され、同特例は特定の資産の固定資産税を不均一に重課するので違法ということになり、地方税法が特例規定を設けた意味は全く失なわれてしまうのである。本件条例はあくまでも地方税法自体が規定している第72条の19の特例に基づき定められたものであり、したがって、本件条例の適法性は当該特別規定の要件を充足しているかどうかで判断されるべきものである。原告のように、本件条例を特例規定と一般規定である地方税法6条2項にも適合していなければならないとすると、本件特例規定で定められているガス供給業者に対する課税標準の特例も事業者のうち特定業種に対する不均一課税をもたらすので、地方税法6条2項が適用され、その結果、不均一に重課する結果となるので違法という奇妙な結果になる。このような奇妙な議論を避けるには、本件条例が特定業種全体ではなく、銀行業のうち一定のものに限定しているので、不均一を問題にするのだというほかなくなるが、これは結局、本件外形標準特例が特定の事業のうちの一部のみに特例を適用することを認めているのか、それとも特定の事業を設定した場合には当該事業全体に特例を適用しなければならないと規定しているのか、の問題である。つまり、本件特例が事業全体に適用することを求めているのだとすると、その一部のみに適用する本件条例は不均一課税を持ち出すまでもなく特例違反と言うことになるはずであるし、逆に、業者の一部に特例を適用することも特例

が認めているのであれば、特例適用の要件を満たしている以上不均一課税は問題にならないことになる。要するに、特例適用要件の解釈問題にすぎないのである。

この点について述べれば、前述のように、本件特例は「特定の事業全体」のみに特例を認めた規定ではなく、具体的な制約条件を付さずに「事業の状況」という抽象的な要件にとどめ、税負担増についても「著しく均衡を失してはならない」という条件にし、多少の不均衡が生じることを認め、外形標準課税制度を自治体の判断で柔軟に導入できる余地を広く認めているのである。このような地方税法の規定からすると、本件条例が地方税法第72条の19の要件に反しているとは到底いえないのであり、そうである以上、不均一課税を問題にする余地もないものと解される。

(11) 原告はさらに、本件条例が法定外新税であることを根拠にした手続違反も論じているが、本件条例が法定外新税であるという前提自体が誤っているので、もはや言及する必要もないと思われる。

(12) 以上のように、本件条例は地方税法の認めた範囲内のものであるから、原告が主張する憲法違反のうち憲法第94条違反はそもそも問題とならない。原告が主張するもう一つの憲法第14条違反の問題については、本件条例はむしろ憲法14条を実質化するために導入されていることを強調しておかねばならない。前述のように、事業税は事業に対して、その事業規模から生じる担税力にふさわしい課税を実現しなければならないものである。大阪府が本件条例を導入する前の数年間の状態は、大手銀行の業務粗利益が大幅に増加し、役員報酬も中小企業では考えられない高額を支給し、株主に対し配当も行い、なおかつ事業税負担が著しく減少し平成元年比で29～4%にすぎなくなっていたのである（乙第16号証）。他方で、不況に悩む中小零細企業は、銀行の融資を受けるために赤字にできず、そのため経営者自身の報酬をきわめて低額にし、ましてや配当などの余力もない状況でも、所得基準に基づき事業税を負担しているのである。この不平等感があったからこそ、通常増税には批判的な住民の多くが歓迎したともいえるのである。平等原則は重要であり、租税負担は負担能力にできるだけ相応していなければならないが、負担能力を測る基準は「所得」だけではなく、事業の場合には業務粗利益をはじめとして様々な合理的な基準もあり得ること、平等原則からすれば経済的強者が負担しないですんでいることの是正が必要であることを指摘しておきたい。いずれにせよ、本件条例は憲法14条に反するものではなく、全く逆に憲法14条を積極的に実質化するための租税条例であることが忘れられてはならないように思われる。

IV おわりに

上記のように、地方税法を体系的に理解すれば本件条例を違法とする余地はないはずである。ところが、本件条例とほぼ同内容の東京都税条例を東京地裁判決は地方税法72条の19に反し違法、無効と判断した。しかし、その判決内容は本当に事業税を法的に精査したうえでなされたものなのであろうか。筆者は判決文を何度も読み直してみたが、そのたびに、なぜこのような基本的な誤解をした判断が、複数の裁判官が関与するはずの税務訴訟においてなされてしまったのか、という疑問を抱かざるを得ない。地方税法を体系的

に精査した上で解釈しないで、あらかじめ自治体敗訴の結論を出した上で、結論を合理化するために税法の解釈を相当強引に歪め、場合によっては初歩的な誤解をしたまま結論を正当づけている、といわざるを得ない。あまりにも重大な誤りを犯しているように思われる。その意味でも、大阪地裁が、地方税法の条文を体系的に精査されて、事業税の本来の性格にふさわしい解釈をされて、本件条例の適法性を示されることを切望したい。

意見書作成者の略歴及び主要著書

一 略歴

昭和25年生まれ
昭和48年 3月 中央大学法学部卒業
昭和50年 3月 一橋大学大学院法学研究科公法専攻修士課程修了
昭和50年11月 同博士課程中退・日本大学法学部助手
昭和55年 4月 静岡大学人文学部法学科専任講師
昭和55年10月 同 助教授
平成 4年 4月 東京大学社会科学研究所助教授併任
(5年3月まで)
平成 5年 3月 法学博士(一橋大学)
平成 5年 4月 静岡大学人文学部法学科教授
平成 6年 4月 立命館大学法学部教授 現在に至る
(なお、平成10年4月～10月 ミュンスター財政裁判所客員裁判官)

二 主要著書

2001年 有斐閣『よくわかる税法入門』
清文社『世界の税金裁判』(編・著)
清文社『税理士春香の事件簿』
2000年 一粒社『相続・贈与と税』
1998年 ぎょうせい『逆転裁決精選50』(編・著)
1995年 信山社『受益者負担制度の法的研究』(日本不動産学会著作賞・東京市政調査会藤田賞受賞)
勁草書房『争点相続税法』(編・著)
1992年 勁草書房『現代税法と人権』
日本住宅総合センター『ドイツの住宅税制』(編・著)
1990年 青木書店『消費税の研究』(共著)
1988年 ぎょうせい『租税手続法活用事典』
1986年 有斐閣『うまい酒と酒税法』(編・共著)
1982年 有斐閣『地方自治法の論点』(共著)
その他、学術論文、等多数。

上記に相違ありません。

平成14年9月27日

立命館大学法学部教授 三 木 義 一